

【논문】

기간제 근로자의 근로계약 갱신기대권 법리*

- 대법원 2011.4.14. 선고 2007두1729 판결을 중심으로 -

오윤식

법률사무소 로정, 변호사

lawjung21@naver.com

<국문초록>

대법원은 지난해 ‘근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권 법리’를 선고하였는데, 이 법리는 기간제 근로자의 근로관계 존속 보호를 위한 법리로 필자는 이에 대하여 지지한다.

필자는 그 법리에 대해 이론적 해명을 시도하였는데, 이는 다음과 같다. 첫째, 기간제 근로자의 근로계약 갱신기대권의 근거는 인간의 존엄성 보장을 위한 근로조건 법정주의 제한을 받는 신뢰책임이다. 둘째, 그 기대권을 인정하는 확정된 판결 또는 판정이나 사용자의 의사표시의 존재를 정지조건으로 하는 조건부 권리로, 그 조건의 성취시 기간제 근로자는 이를 완전한 권리로서 취득한다. 셋째, 갱신된 기간이 만료 되더라도 사용자가 기간 만료를 주장하는 것은 금반언의 법리에 반하여 허용되지 않고 법원이나 노동위도 갱신된 기간 만료로 인한 소의 이익의 부존재를 이유로 각 하판결을 해서는 안 되며, 예외적인 그 기대권의 제한사유가 없는 한 그 주장이 차단되는 시기는 정규직 근로자의 정년이 도래할 때까지이다. 넷째, 근로자는 그 기대권에 관한 구체적 사정을 입증하여 법원 등으로부터 그 기대권의 존재를 인정받아야 하고, 사용자는 근로계약 갱신 거절의 정당성을 입증해야 한다.

주제어: 기간제 근로자, 갱신기대권, 신뢰책임, 근로조건법정주의, 근로관계 존속 보호

* 심사위원: 김인재, 송강직, 조경배

투고일: 2012.10.3. 심사개시: 2012.10.5. 게재확정: 2012.10.15.

* 심사위원: 김인재, 송강직, 조경배

투고일: 2012.10.3. 심사개시: 2012.10.5. 게재확정: 2012.10.15.

— <차 례> —

- I. 대상판결의 개요
- II. 기간제 근로자의 근로계약 갱신기대권 법리
 - 1. 대법원 1996.8.29. 선고 95다5783 판결(전원합의체)과 그 이후의 상황
 - 2. 기간제 근로자의 근로관계 존속 보호 법리에 관한 판례의 검토
 - 3. 대상판결의 고찰
- III. 결론에 부쳐

I. 대상판결의 개요

1. 사실관계

원고들은 서울시 산하 참가인인 서울특별시시설안전공단(이하 ‘참가인’이라 함)과 2002년 12월 9일부터 2003년 12월 31일까지로 하는 위·수탁 계약)(이하 ‘이 사건 계약’이라 함)을 체결하고 장애인콜택시의 운행업무를 수행하여 왔는데, 참가인은 이 사건 계약기간이 만료되기 이전인 2003년 11월경 계약연장 여부를 결정하기 위하여 심사위원회를 구성한 다음, 기준항목 총점 70점 이상자에 대하여는 연장계약을 체결하여 이 사건 계약을 갱신하며 총점 70점 미만자에 대하여는 이 사건 계약의 갱신을 거절하여 그 계약을 종료시키기로 하는 심사기준을 마련하였다.

참가인은 그 심사기준에 따라 70점 미만자에 해당하는 원고들 등 운전자 11명에 대하여 2003년 12월 31일자로 계약이 종료됨을 통보하여 이 사건 계약의 갱신 거절(이하 ‘이 사건 갱신 거절’이라 함)을 하고, 나머지 운전자 89명과의 사이에 연장계약을 체결하는 형식으로 이 사건 계약을 갱신하였다.

3) 본 사안의 경우 근로기준법상 근로자성도 큰 쟁점이 되었으나, 1심 및 항소심 모두 그 근로자성을 인정하여 대법원이 이에 대하여 판단을 하지 않았으므로 그 쟁점 및 사실관계는 평석의 범위에서 제외한다.

2. 재판의 경과

원고들은 2004년 1월 26일 참가인의 이 사건 갱신 거절은 부당노동행위⁴⁾ 및 부당해고에 해당된다고 주장하면서 서울지방노동위원회에 2004부노10, 부해89호로 부당노동행위 및 부당해고 구제신청을 하였고, 위 지방노동위원회는 2004년 4월 20일, 원고들이 이 사건 계약의 위탁기간이 2003년 12월 31일에 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계가 종료되어 참가인의 이 사건 갱신 거절이 해고에 해당한다고 볼 수 없고, 원고들이 노조활동을 하였다는 이유로 참가인이 계약갱신을 거부하였다고 보기도 어려워 부당노동행위에도 해당하지 않는다고 판단하여 원고들의 위 구제신청을 모두 기각하였다. 원고들은 이에 불복하여 중앙노동위원회에 2004년 5월 29일 2004부노80, 부해358호로 재심신청을 하였고, 중앙노동위원회는 2004년 10월 13일 위와 동일한 판단 하에 원고들의 재심신청을 모두 기각하는 재심판정을 하였고, 원고들은 2004년 11월 2일 그 재심판정의 취소를 구하는 소송을 서울행정법원에 제기하였다.

3. 1심⁵⁾과 항소심⁶⁾의 판결 요지

1심 재판부는 원고들이 종사한 사업의 특성, 수탁기관이 제3자에게 업무를 재위탁하는 경우 계약기간은 1년 단위로 하도록 규정하고 있는 등 위 계약의 계속적 유지가 보장되어 있는 것으로는 단정하기 어려운 사정 등을 들어, 이 사건 계약에서 정한 위탁기간이 형식에 불과하여 이 사건

4) 원고들을 비롯한 이 사건 계약을 체결한 일부 운전자들은 2003년 8월 6일 산업별노동조합의 산하지부 형태로 서울경인사회복지노동조합 서울시장에인콜택시지부를 명칭으로 한 노동조합을 설립한 다음, 2003년 10월 10일부터 참가인과의 단체교섭을 요구하여 2003년 11월 8일 단체교섭이 이루어졌는데, 이 사건 갱신 거절 당시 조합원들은 22명 정도였고, 원고들은 위 노조지부의 임원들로서 원고 1은 지부장, 원고 3은 사무국장, 원고 2는 부지부장, 원고 5는 조직부장, 원고 6은 총무부장, 원고 4는 교선부장으로 각각 활동하였다.

5) 서울행정법원 2005.7.7. 선고 2004구합33756.

6) 서울고등법원 2006.12.19. 선고 2005누17722.

계약을 사실상 기간의 정함이 없는 계약으로 볼 수 있다는 원고들의 주장을 배척하였다.

하지만 1심 재판부는 “원고들로서는 위탁기간이 만료된 후에도 계속 근로관계가 유지될 것으로 기대할 만한 충분한 사정이 있었다고 볼 수 있어, 이 사건 계약상의 위탁기간은 그 만료로써 계약관계가 확일적으로 종결되는 존속기간이 아니라 갱신에 의하여 연장이 허용되는 갱신기간이라고 봄이 옳고, 이러한 경우 해고제한의 법리가 유추적용되어 사회통념상 상당하다고 인정되는 합리적인 이유 없이 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 신의칙상 허용될 수 없다고 할 것이며(다만, 이것은 기간의 정함이 없는 근로계약에 직접 적용되는 정당한 이유라는 해고제한의 기준보다는 완화된 기준인 점에서 해고제한의 법리가 그대로 적용되는 것이 아니라 유추적용되는 것이다), 이러한 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약인 이 사건 계약이 갱신된 것과 동일하다고 보아야 할 것”이라고 판단한 다음, 참가인이 일부 문제가 있는 이 사건 심사항목을 그나마도 운전자들에 대하여 공평하게 적용하지 아니하고 자의적으로 적용한 결과로서 총 점수가 70점 미만이 된 점 등에 비추어 볼 때, 갱신 거절의 합리성도 없어서 참가인의 원고들에 대한 이 사건 갱신 거절은 그 효력을 인정할 수 없다고 판단하여 중앙노동위의 재심판정을 취소하는 판결을 하였다.

그런데, 항소심 재판부는 참가인에게 이 사건 계약서 및 관련 법령 등에 위 계약기간이 만료된 원고들 등에 대하여 재계약(재임용)을 체결할 의무를 지우거나 구체적인 재계약절차 및 요건 등에 관하여 아무런 규정을 두고 있지 아니한 사정, 원고들의 경우에는 계약갱신이 단 한 차례도 이루어지지 않은 사정 등에 비추어 볼 때, 재임용될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되지 않고, 나아가 참가인은 총점 70점 미만자인 원고들과 사이에 이 사건 계약의 갱신을 거절할 합리적인 사유도 갖추었다고 판단하여 위 1심 판결을 취소하였다.

4. 대법원의 판단 요지

한편 대법원은, “기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그

기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신 거절의 의사표시가 없어도 당연 퇴직되는 것이 원칙이다. 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다”라고 기간제 근로자의 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권 법리를 판시하였다.⁷⁾

또한 대법원은 위와 같은 법리에 기초하여, “서울특별시의 장애인콜택시 운영계획에 계약기간을 1년 단위로 갱신하도록 하면서 그 취지가 부적격자의 교체에 있음을 명시하고 있고, 장애인콜택시 사업을 한시적·일시적 사업이라고 볼 수 없는 점, 위·수탁 계약에서 위탁기간 연장 규정을 두고 있는 점 등을 종합하면, 갑 등을 비롯한 위 시설관리공단 소속 운전자들에게는 기간제 근로계약이 갱신되리라는 정당한 기대권이 인정된다고 보아야 하고, 위 공단이 공정성 및 객관성이 결여된 심사과정을 거쳐 갑 등에 대하여 갱신 기준 점수 미만이라는 점을 들어 위 계약의 갱신을 거절한 것은 정당성을 결여하여 효력이 없음에도, 이와 달리 본 원심판결에 기간을 정한 근로계약 등에 관한 법리를 오해한 위법이 있다”고 판단하여 항소심 판결을 파기환송하였다.⁸⁾

7) 대법원 2011.4.14. 선고 2007두1729.

8) 그 후 파기환송심을 담당한 서울고등법원은 피고의 항소를 기각하는 판결을 선고하였고(서울고등법원 2011.8.31. 선고 2011누13103), 이 판결은 피고가 재상고하지 않아 최종 확정되었다.

II. 기간제 근로자의 근로계약 갱신기대권 범위

1. 대법원 1996.8.29. 선고 95다5783 판결(전원합의제)과 그 이후의 상황

1.1. 대법원 1996.8.29. 선고 95다5783 판결(전원합의제)

구 근로기준법 제21조는 계약기간이라는 표제 아래 “근로계약은 기간의 정함이 없는 것과 일정한 사업완료에 필요한 기간을 정한 것을 제외하고는 그 기간은 1년을 초과하지 못한다”고 규정하였는데,⁹⁾ 이 조항과 관련하여 대법원은 다음과 같이 판시하였다.

즉, 대법원은 “(근로기준법 제21조) 그 입법취지는 장기의 근로기간을 정함으로 인하여 근로자가 퇴직의 자유를 제한당하게 됨으로써 장기간 근로의 계속을 강요당하는 것을 방지할 목적으로 근로자 보호를 위하여 1년을 초과하는 근로계약기간 부분의 근로관계에 있어서 근로자에게 퇴직의 자유를 보장하려는 것에 있고, 근로계약기간은 단지 근로계약의 존속기간에 불과할 뿐 ‘근로관계에 있어서 임금·근로시간·후생·해고 등 근로자의 대우에 관하여 정한 조건’을 의미하는 근로기준법 제20조 소정의 근로조건에 해당하지 아니하므로 근로계약 당사자는 원칙적으로 이를 임의로 정할 수 있으며, 따라서 1년을 초과하는 근로계약기간을 정하여 근로계약을 체결하였다 하더라도 그 계약기간의 정함 자체는 유효하므로 약정기간 범위 내에서는 사용자는 근로기준법 제21조를 근거로 단순히

9) 이 조항은 1997년 3월 13일 법률 5309호로 제정된 근로기준법 제23조에 같은 내용으로 규정되었다가, ‘기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률’(이하 ‘기간제법’이라 함)이 제정됨에 따라 2006년 12월 21일 법률 제8074호로 개정된 근로기준법에서 삭제된 후, 2007년 4월 11일 법률 제8372호로 전부개정된 근로기준법 제16조에 “근로계약은 기간을 정하지 아니한 것과 일정한 사업의 완료에 필요한 기간을 정한 것 외에는 그 기간은 1년을 초과하지 못한다”고 일부 자구 변경이 되어 규정된 다음(부칙 제3조에 의해 2007년 6월 30일까지만 효력을 가지도록 규정), 2006년 12월 21일 법률 제8074호로 제정된 기간제법 제4조가 2007년 7월 1일부터 시행됨에 따라 효력을 상실하였다.

근로자에게 1년의 기간이 경과하였음을 이유로 근로관계의 종료를 주장할 수 없고 다만 근로자로서는 1년이 경과한 후에는 언제든지 당해 근로계약을 해지할 수 있다 할 것이며, 한편 근로계약기간을 정한 경우에 있어서 근로계약 당사자 사이의 근로관계는 특별한 사정이 없는 한 그 기간이 만료함에 따라 사용자의 해고 등 별도의 조치를 기다릴 것 없이 당연히 종료된다”고 판시한 다음, 1년을 초과하는 근로계약기간을 정한 경우에 그 근로계약은 1년의 계약기간을 가진 근로계약으로 인정되고 그 이후의 근로관계는 특별한 사정이 없는 한 기간의 정함이 없는 것으로 보아야 할 것이라고 판시한 대법원 1989.7.11. 선고 88다카21296 판결을 폐기하였다.

1.2. 대법원 95다5783 판결 이후의 상황

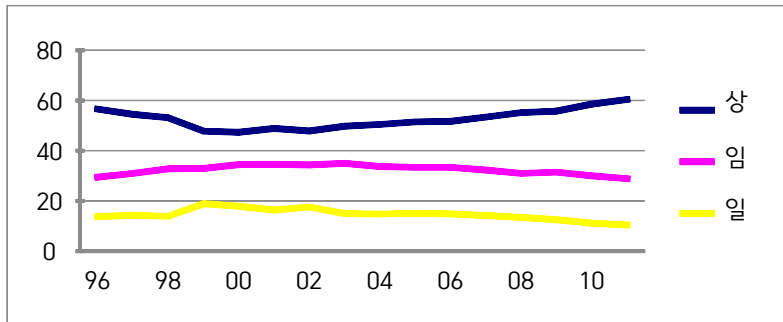
근로자가 근로계약기간을 정한 근로계약을 체결한 경우 그 계약기간이 만료된 때에는 사용자와의 근로관계는 당연히 종료되어 고용불안을 겪을 수밖에 없게 되었고, 반면 사용자는 정당한 이유가 있어야 인정되는 해고제한 법리의 적용을 합법적으로 회피할 수 있게 되었다. 그리하여 사용자는 기간의 정함이 없는 근로계약 대신 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결할 유인이 생기게 되었고, 그 결과 기간제 근로자는 시대적 큰 흐름이 되기에 이르렀다(다음 그래프¹⁰⁾ 참조, 다만 그 그래프에서 기간제 근

¹⁰⁾ 위 그래프는 아래와 같은 전체 임금근로자 중에서 상용근로자, 임시근로자, 일용근로자가 각각 차지하는 비율의 변화를 나타내는 것으로, 위 전원합의체 판결이 선고되기 직전인 1996년 7월과 1997년부터 2011년까지 매년 6월의 그 비율을 나타내는 그래프이다. 그 비율은 아래 표의 위 기간 동안 ‘종사상지위별 취업자’의 인원{통계청, “종사상지위별 취업자”, <http://kosis.kr/gen_etl/start.jsp?orgId=101&tblId=DT_1DA7010&conn_path=I2&path=고용?노동?임금> 고용> 경제활동인구조사 > 취업자(63년~현재)종사상지위별 취업자}, 검색일: 2012. 7.6. }을 기초로 하여 전체 임금근로자 중에서 상용근로자, 임시근로자, 일용근로자가 각각 차지하는 비율이다. 다만, 위 종사상지위별 취업자의 통계에서는 아래 표에 기재된 비율은 나오지 않는데 필자가 그 비율을 계산하여 그 표에 별도로 기재한 것임을 밝혀둔다.

(단위: 1,000명, 괄호 안은 %)

로자가 포함된 임시근로자가 전체 임금근로자 중에서 차지하는 비율이 2003년을 정점으로 점차 감소하는 것으로 나타나고 있다).

이러한 상황의 전개는 위와 같은 전원합의체 판결과 일정 정도 상관관계가 있다고 본다. 즉 1년을 초과하는 근로계약기간을 정한 근로계약의 경우에도 그 기간 정함 자체는 유효하고 그 기간이 만료함에 따라 사용자의 해고 등 별도의 조치를 기다릴 것 없이 근로관계는 당연히 종료된다고 보는 것으로 판례가 변경되었기 때문에, 사용자는 기간의 정함이 있는 근로계약을 그 판례 변경 이전보다 더 수월하게 이용할 수 있게 되었고, 이는 결국 기간제 근로자의 증가와 연결되었기 때문이다.



〈전체 임금 근로자 중 상용근로자, 임시근로자, 일용근로자가 각각 차지하는 비율〉

그리고 2010 고용형태별근로실태조사 보고서에 따르면, 기간제 근로자의 월급여는 1,585,000원으로 월급여가 2,285,000원인 정규직 근로자의 69% 수준에 불과하며, 상여금 적용률의 경우 정규직 근로자가 75.9%인 반면, 기간제 근로자가 47.2%이고, 노조가입률의 경우도 정규직 근로자가

	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	07	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
임금 근로자	13,302	13,511	12,263	12,755	13,473	13,838	14,308	14,525	15,058	15,401	15,716	16,124	16,385	16,736	17,193	17,720
상용 근로자	7,536 (56.6)	7,370 (54.5)	6,533 (53.2)	6,119 (47.8)	6,394 (47.4)	6,773 (48.9)	6,862 (47.9)	7,245 (49.8)	7,606 (50.5)	7,931 (51.5)	8,131 (51.7)	8,617 (53.4)	9,039 (55.2)	9,340 (55.8)	10,089 (58.6)	10,716 (60.4)
임시 근로자	3,929 (29.5)	4,191 (31.0)	4,023 (32.8)	4,228 (33.0)	4,655 (34.5)	4,788 (34.6)	4,923 (34.4)	5,086 (35.0)	5,228 (33.7)	5,144 (33.4)	5,246 (33.4)	5,217 (32.3)	5,132 (31.3)	5,281 (31.5)	5,165 (30.0)	5,132 (28.9)
일용 근로자	1,838 (13.8)	1,950 (14.4)	1,706 (13.9)	2,408 (18.9)	2,425 (17.9)	2,277 (16.4)	2,523 (17.6)	2,193 (15.0)	2,225 (14.8)	2,326 (15.1)	2,339 (14.9)	2,290 (14.2)	2,214 (13.5)	2,115 (12.6)	1,938 (11.2)	1,872 (10.5)

14.8%인 반면, 기간제 근로자의 경우 3.2%에 불과하다.¹¹⁾ 이러한 점을 고려하면, 기간제 근로자의 근로조건은 정규직 근로자에 비하여 매우 열악하며 노조에 가입하는 비율도 정규직 근로자의 그것에 비하여 매우 낮은 것을 알 수 있다.

위와 같은 상황에서 열악한 근로조건에 놓인 기간제 근로자의 고용보장을 확보하는 법리의 모색과 관련하여, 이하에서는 기존 판례를 검토한 다음 대상판결의 법리를 검토한다.

2. 기간제 근로자의 근로관계 존속 보호 법리에 관한 판례의 검토

2.1. 기간제 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 간주하는 법리

우리 대법원이 기간제 근로자를 보호하는 법리를 선고한 최초의 판결은 이른바 연세여학당 사건이다. 즉 이 사건에서 대법원은 “기간을 정하여 채용된 근로자라고 할지라도 장기간에 걸쳐서 그 기간의 갱신이 반복(그 판단요소¹²⁾)되어 그 정한 기간이 단지 형식에 불과하게 된 경우(인정요건)에는 사실상 기간의 정함이 없는 근로자의 경우와 다를 바가 없게 되는 것(그 법적 효과)이고, 그 경우에 사용자가 정당한 사유 없이 갱신계약의 체결을 거절하는 것은 해고와 마찬가지로 무효이다”라고 판시하여, 기간제 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 ‘사실상’ 간주하기 위한 요건, 그 판단요소 및 법적 효과를 밝혔다.¹³⁾

대법원은 그 후 몇 차례 같은 취지로 판결을 선고한 후,¹⁴⁾ “처음으로 근로계약을 체결하면서 기간을 정한 근로계약서를 작성한 경우 그 근로계약이 계약서의 문언에 반하여 기간의 정함이 없는 근로계약이라고 하기 위해서는(그 법적 효과) 계약서의 내용과 근로계약이 이루어지게 된

11) 고용노동부, “2010 고용형태별근로실태조사 보고서”, 15-29쪽, <<http://laborstat.moel.go.kr/include/download.jsp?filepath=/labor/fileload/pdata/&filename=2010년고용형태별근로실태조사보고서.pdf>>, 검색일: 2012.7.13.

12) 밀줄과 괄호안의 설명 및 강조는 필자가 임의로 한 것이다. 이하 같다.

13) 대법원 1994.1.11. 선고 93다17843; 대법원 2003.11.29. 선고 2003두9336.

14) 대법원 1995.7.11. 선고 95다9280; 대법원 1998.1.23. 선고 97다42489.

동기 및 경위, 기간을 정한 목적과 당사자의 진정한 의사, 동종의 근로계약 체결방식에 관한 관행 그리고 근로자보호법규 등(그 판단요소)을 종합적으로 고려하여 그 기간의 정함이 단지 형식에 불과하다는 사정이 인정(인정 요건)되어야 한다”고 판시하여, 기간제 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 ‘법률상’ 간주하기 위한 요건의 판단요소, 그 법적 효과를 밝혔다.¹⁵⁾ 이 판례가 위 93다17843 판결과 다른 점은, 첫째 기간제 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 간주하기 위한 요건의 판단요소가 ‘장기간에 걸쳐서 그 기간의 갱신이 반복’에서 ‘동종의 근로계약 체결방식에 관한 관행’ 등의 종합적 고려로 진화되었다는 점이고, 둘째, 그 법적 효과를 ‘사실상’ 기간제 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 간주하는 것에서 ‘법률상’ 그 근로자로 간주하는 점으로 변경¹⁶⁾되었다는 것이다.

그 후 대법원은 “근로계약기간을 정한 근로계약서를 작성한 경우 처분 문서인 근로계약서의 문언에 따라 특별한 사정이 없는 한 근로자와 사용자 사이에는 기간의 정함이 있는 근로계약을 맺었다고 보아야 하고, 이 경우 근로계약기간이 끝나면 그 근로관계는 사용자의 해고 등 별도의 조치를 기다릴 것 없이 당연히 종료함이 원칙이고, 다만 기간을 정한 근로계약서를 작성한 경우에도 예컨대 단기의 근로계약이 장기간에 걸쳐서 반복하여 갱신됨으로써 그 정한 기간이 단지 형식에 불과하게 된 경우 등 계약서의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 기간을 정한 목적과 채용 당시 계속근로 의사 등 당사자의 진정한 의사, 근무기간의 장단 및 갱신 횟수, 동종의 근로계약 체결방식에 관한 관행 그리고 근로자보호법규 등(그 판단 요소)을 종합적으로 고려하여 그 기간의 정함이 단지 형식에 불과하다는 사정이 인정(인정 요건)되는 경우에는 계약서의 문언에도 불구하고 사실상 기간의 정함이 없는 근로계약을 맺었다고 볼 것(그 법적 효과)이며, 이 경우 사용자가 정당한 사유 없이 갱신 계약 체

15) 대법원 1998.5.29. 선고 98두625.

16) ‘법률상’ 그 근로자로 간주하는 점은 대법원 2006.2.24. 선고 2005두5673에서도 확인된다.

결을 거절하는 것은 해고와 마찬가지로 무효이다”¹⁷⁾ 이 대법원 판결이 98두625 판결과 다른 점은, 첫째, 기간의 정함이 단지 형식에 불과한 사정의 범주를 장기간에 걸쳐서 반복하여 갱신된 경우와 여러 요소를 종합적으로 고려하여 기간의 정함이 단지 형식에 불과한 경우로 유형화하고, 전자는 후자의 하나로 예시하고 있다는 것이고, 둘째, 그 법적 효과를 ‘사실상’ 기간제 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 간주하는 것에 그쳤다는 점이고, 셋째, 그 판단요소의 하나로 ‘근무기간의 장단 및 갱신 횟수’를 추가하였다는 것이다.

2.2. 대학교원이나 연구원의 재임용에 대한 정당한 기대권 법리

한편, 대법원은 한국문화정책개발원 연구원 사건에서 “계약기간을 정하여 임용된 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 재임용계약을 체결하지 못하면 재임용거부결정 등 특별한 절차를 거치지 않아도 당연퇴직되는 것이며, 근로자가 부당해고구제신청을 하여 해고의 효력을 다투던 중 계약기간의 만료로 근로관계가 종료되었다면 더 이상 구제절차를 유지할 필요가 없게 되어 구제이익이 소멸하는 것이 원칙이기는 하나, 임용의 근거가 된 법령 등의 규정이나 계약 등에서 임용권자에게 임용기간이 만료된 근로자를 재임용할 의무를 지우거나 재임용절차 및 요건 등에 관한 근거규정을 두고 있어 근로자에게 소정의 절차에 따라 재임용될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 그 절차에 위반하여 부당하게 근로자를 재임용에서 제외하는 것은 실질적으로 부당해고와 동일시할 수 있는 것이므로 근로자로서는 임용기간이 만료된 후에도 재임용에서 제외한 조치의 유효 여부를 다룰 법률상 이익을 가진다”라고 판시하였다.¹⁸⁾

이러한 판결은 교수임용제도에 관한 헌법재판소와 대법원 판례 변화로부터 직·간접적으로 영향을 받은 것으로 추측된다.¹⁹⁾ 즉, 헌법재판소가

17) 대법원 2007.9.7. 선고 2005두16901; 대법원 2010.6.24. 선고 2007다31471.

18) 대법원 2005.7.8. 선고 2002두8640.

19) 도재형, “기간제 근로계약 갱신 거절권의 제한”, 노동법연구 제24호(서울대노동

사립학교법이 재임용에 관한 기준과 소명절차, 사전통지 절차 및 사후 구제절차를 마련하지 않은 것은 헌법 제31조 제6항상 교원지위법정주의에 위반된다고 선고한 이후,²⁰⁾ 대법원은 “기간제로 임용되어 임용기간이 만료된 국·공립대학의 조교수는 교원으로서의 능력과 자질에 관하여 합리적인 기준에 의한 공정한 심사를 받아 위 기준에 부합되면 특별한 사정이 없는 한 재임용되리라는 기대를 가지고 재임용 여부에 관하여 합리적인 기준에 의한 공정한 심사를 요구할 법규상 또는 조리상 신청권을 가진다고 할 것”이라고 판시하였는데,²¹⁾ 위 판결은 위와 같은 판례의 영향을 받아 선고된 것으로 판단되는 것이다.

이후 대법원은 대학교 전산부서에 근무한 기간제 근로자가 제기한 부당해고무효확인사건에서, 위 대법원 2005.7.8. 선고 2002두8640 판결의 법리를 수용하는 판결을 하였다.²²⁾ 다만 그 판례는 대학교원이나 연구원이 아닌 대학교에 근무하는 기간제 근로자에 대하여도 재임용에 대한 정당한 기대권 법리를 적용하고 있다는 점이 특이하다. 이러한 점을 볼 때 대학교원이나 연구원의 재임용에 대한 정당한 기대권 법리는 기간제 근로자의 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권 법리의 징검다리 역할을 했다고 볼 수 있다.

3. 대상판결의 고찰

3.1. 기간제 근로자의 근로관계 존속 보호를 위한 기존의 논의와 대상판결의 의의

위 대법원 1996.8.29. 선고 95다5783 판결(전원합의체) 이후 급증하는 기간제 근로자의 근로관계 존속을 보호하기 위하여 다양한 의견이 개진된 바 있다.

법연구회, 2008), 176-177쪽; 김인재, “기간제 근로자의 재임용 기대권”, 월간노동법률 제174호(중앙경제사, 2005), 38쪽.

20) 헌법재판소 2003.2.27. 2000헌바26.

21) 대법원 2004.4.22. 선고 2000두7735(전원합의체).

22) 대법원 2007.10.11. 선고 2007두11566.

강성태 교수는 1년을 초과하는 근로계약은 일정한 사업의 완료에 필요한 경우를 제외하고는 탈법을 목적으로 한 것으로 애초부터 기간을 정하지 않은 근로계약이 체결된 것으로 보아야 한다고 하면서, 기간을 정한 근로계약의 경우 그 기간의 만료에 의하여 자동적으로 근로관계가 종료되는가 하는 문제와 관련해서는, 일시적, 임시적 수요의 증가와 같이 기간을 설정할 합리적이고 객관적인 사유가 있는 경우에는 원칙적으로 기간의 만료에 의해 근로관계는 종료되는 것이고, 이에는 사용자의 해지 내지 해고의 의사표시는 불필요하고, 반면에 기간설정의 객관적·합리적 사유가 없는 경우에는 처음부터 기간의 정함이 없는 근로계약이 체결된 것으로 보아 기간의 만료에 의해 자동적으로 근로관계가 종료되는 것은 아니고 사용자가 근로관계를 종료시키기 위해서는 해고의 의사표시가 필요하며, 이에는 정당한 이유가 있어야 한다고 한다.²³⁾²⁴⁾ 또한 조임영 교수는 입법자가 근로관계의 존속을 보호하기 위하여 해고제한에 관한 법규정을 두었다면 이러한 입법자의 결단은 전체 범질서 안에서 실현되어야 할 것이므로 구 근로기준법 제23조의 근로계약기간에 관한 해석은 해고제한 규정과의 관계 속에서 일정한 제한을 받을 수밖에 없는데, 기간의 약정이 불가피한 객관적인 사유가 없는 경우에는 사용자는 기간의 약정을 주장할 수 없으며, 오히려 기간의 정함이 없는 근로관계로서 효력을 갖게 되는 것으로 해석하는 것이 타당하다고 본다.²⁵⁾ 이은영 교수는 근로기준법의 해고 제한 규정의 기본취지가 근로관계의 존립 보호에 있고 따라서 근로관계의 존속기간의 약정이 불가피하게 요구되는 ‘객관적인 사유’가 존재하지 않음에도 불구하고 기간의 만료로 인하여 근로관계가 당연히 종료된다고 하면 해고를 제한하는 근본취지가 부정될 가능성이 있기 때문에, 근로관계가 존속기간의 약정이 있다고 하여 그 기간의 만료로

23) 강성태, “기간제 정함이 있는 근로계약의 규율”, 노동법학 제7호(한국노동법학회, 1997), 188-189쪽.

24) 김형배 교수도 예전에는 강성태 교수와 동일 취지의 견해를 취한 바 있으나, 현재는 그 견해를 변경하였다(김형배, 노동법(박영사, 2007), 540쪽)).

25) 조임영, “기간제 고용에 관한 현행법제의 문제점과 입법적 과제”, 중앙법학 제6집 제3호(중앙법학회, 2004), 418-419쪽.

당연히 종료한다고 할 것은 아니며 기간 만료시에 계약의 갱신을 거절할 타당한 이유가 없는 한 해고의 의사표시와 유사하게 평가되어야 할 것이므로, 기간의 약정이 불가피한 객관적인 사유가 없는 경우에는 사용자는 기간의 약정을 주장할 수 없으며 오히려 기간의 정함이 없는 근로관계로서 효력을 갖게 된다고 한다.²⁶⁾

한편, 노상헌 교수는 ‘근로계약의 종료’와 ‘근로관계의 종료’를 구분하면서 ‘갱신되어온 유기근로계약’ 또는 ‘근로자가 갱신되는 것으로 기대하고 있는 유기근로계약’은 명시적 기간의 정함이 있는 한 기간만료로 종료하나, 근로자가 그 기간이 도과했음에도 불구하고 노무 제공의 의사를 가지고 있는 경우에는, 사용자는 묵시의 갱신을 피하기 위하여 명시적으로 노무 수령 거부 의사 표시를 할 필요가 있고, 사용자가 계약 갱신을 명시적으로 거부할 때에는 당해 ‘근로관계’는 기간 만료와 함께 종료하는 것으로 본다. 사용자의 이러한 ‘확정적 종료의사’는 종료하는 유기근로계약의 갱신 거부가 아니라 계속될 ‘근로관계’의 명시적 거부이며, 근로자의 의사에 반하여 행하여지는 사용자의 ‘근로관계’의 명시적 종료야말로 ‘해고’에 해당한다고 본다.²⁷⁾ 또한, 도재형 교수는 우리 헌법상의 인간의 존엄과 가치, 근로권은 일용 근로기준법 제23조 소정의 정당한 이유를 매개로 구현된다고 볼 수 있고, 결국 기간제 근로계약의 갱신 거절이 유효한지는 근로기준법 제23조의 적용 문제로 귀결된다고 한다.²⁸⁾ 그리고 유성재 교수는 해고 제한 규정 유추적용설, 배려의무 위반설, 형평성설, 헌법합치적 법해석설, 신뢰보호설 등 기간의 정함이 있는 근로계약의 제한에 대한 독일의 해석론을 소개하면서, ‘기간의 정함이 있는 근로계약’에 대하여 근로관계의 존속을 보호해 줄 수 있는 경우는 신뢰보호설의 입장에 따라 ‘기간의 정함이 있는 근로계약’이 수차에 걸쳐 반복 갱신되어 근로자에게 계약갱신에 대한 신뢰가 형성된 경우로 제한될 것이라고 한다.²⁹⁾

26) 이은영, “임시직 근로자의 계속근로와 퇴직금”, 민사판례연구 제18호(민사판례연구회, 1996), 269쪽.

27) 노상헌, “기간의 정함이 있는 근로계약과 해고법리”, 노동법학 제16호(한국노동법학회, 2003), 21쪽.

28) 도재형, “기간제 근로계약 갱신 거절권의 제한”, 182쪽.

위와 같은 광범위한 학계의 논의가 진행된 상황에서 대법판결은 위와 같이 기간제 근로자의 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권 법리를 실시한 것이다. 이러한 대법원 판례는 이러한 학계의 논의·비판을 수용하는 한편, 다수의 하급심 판례³⁰⁾가 확인한 법리를 대법원 판결로 정교하게 정립하였다는 데 의의가 있다.³¹⁾ 또한 이로써 기간제 근로자의 근로관계 존속을 보호하는 데 크게 이바지할 것이다.

그럼에도 이론적으로 규명되거나 해명되어야 할 부분이 몇 가지 있다. 이하에서는 이에 대하여 살펴본다.

3.2. 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권의 근거

기간제 근로자가 자신의 근로계약이 갱신되리라는 데에 대한 정당한 기대권을 가질 수 있는 근거는 어디에서 찾을 수 있는가? 대법판결은 그 근거를 ‘신뢰관계 형성’, 즉 사용자가 근로자에 대하여 심어준 근로계약 갱신에 관한 신뢰책임³²⁾(Vertrauenshaftung)으로 보는 듯하다.

이러한 판례의 태도는 기본적으로 타당하다. 그러나, 이와 같이 그 근거를 신뢰책임만으로 보면 사용자가 그 신뢰에 대한 벌미를 주지 않으면

29) 유성재, “기간제 정함이 있는 근로계약에 대한 입법론적 고찰”, 노동법학 제12호(한국노동법학회, 2001), 124-128쪽. 위 학설에 대한 자세한 내용은 같은 글 124-128쪽 참조.

30) 서울행정법원 2004.4.8. 선고 2003구합32275; 서울행정법원 2004.10.28. 선고 2004구합8743; 서울행정법원 2005.5.12. 선고 2004구합36274; 서울행정법원 2006.1.5. 선고 2005구합3288; 서울행정법원 2005.9.1. 선고 2005구합8573; 서울중앙지방법원 2009.3.27. 선고 2008가합61153,98711 등.

31) 이러한 대법원 판례는 일본 최고재판소가 판시한 법리를 상당 정도 영향을 받은 것으로 보인다. 다만, 일본 최고재판소는 그 판단요소로 당해 고용의 임시성·상용성, 갱신 회수, 고용의 통산기간, 계약기간의 관리상황, 고용계속의 기대를 가지게 하는 언동·제도의 유무 등이 고려된다고 한다(스게노카즈오 저/이정 역, 일본노동법(박영사, 2007), 181-185쪽).

32) 이 신뢰책임은 타인에 대해 어떤 언동(言動)을 통해 일정한 신뢰를 야기하였고 그 신뢰가 법적으로 보호할 가치가 있는 경우 그 신뢰를 야기한 자가 그 타인에 대해 지는 책임을 말한다. 대표적으로는 민법상 계약체결상의 과실책임(제535조)이 있다.

그 갱신기대권은 발생하지 않게 된다. 즉, 사용자가 근로계약 갱신기대권이 인정되지 않도록 철저하게 노무관리를 하게 되면 그 기대권이 발생할 여지는 없는 것이다. 예컨대, 근로계약을 체결할 때에 기간이 만료하면 당연퇴직한다는 점을 명기하고 그러한 점을 기간 만료 임박 이전에 수시로 근로자에게 주시킴으로써 근로계약 갱신이 인정될 수 있는 제도적 요소(취업규칙이나 단체협약에 기간제 근로자 갱신에 관한 요건 및 절차를 두지 않고 오히려 이를 부인하는 것을 명기하는 등)을 없애는 경우 등의 조치를 취하는 경우에는 그 기대권이 인정되기는 어려울 것이다. 따라서 신뢰책임으로만 그 근거를 삼는다면, 그 갱신기대권이 형해화될 여지가 있다. 이 지점에서 근로자 지위의 본질(本質)로 돌아갈 필요가 있다.

자본주의 사회에서 노동자는 자신의 노동력을 자본가에게 팔지 않고서는 생존을 도모할 수 없다. 다시 말하여 토지, 자본 등 생산수단을 소유하지 못한 근로자는 생산수단을 소유한 사용자에게 자신의 노동력을 팔 수밖에 없고, 이로써 근로자는 그 노동력 제공의 대가인 임금을 지급받아 생활하게 된다. 이러한 임금 획득을 위한 노동력 제공 과정에서 근로자는 사용자의 지휘·명령 하에 근로를 제공하게 됨으로써 사용자에게 대하여 종속되는 결과가 초래되는데, 이를 인적 종속성(persönliche Abhängigkeit)이라 하고, 근로자가 자신의 노동력 전부를 사용자의 처분에 맡김으로써 그와 같은 취업관계가 계속되고 있는 동안은 다른 소득을 얻을 수 없게 되는데, 이를 경제적 종속성(wirtschaftliche Abhängigkeit)이라 한다.³³⁾ 이와 같은 근로자의 노무 제공은 다음과 같은 특성을 지니고 있다. 첫째, 근로자의 노무 제공은 그의 인신과 분리하여 제공될 수 없으므로 근로자의 신체·건강·노동력 유지라는 보호가 요청되며, 둘째, 사용자의 지배영역인 경영조직에서 그의 지시 하에 노무를 제공하므로 근로자는 인격적으로 보호되어야 하며, 셋째, 사용자는 노동력의 수급을 결정·조정할 수 있으므로 임금이나 해고로부터 근로자를 보호할 필요가 있게 된다.³⁴⁾

이러한 종속노동성으로 인하여 열악한 근로자를 보호할 필요성이 제기

33) 김형배, 노동법(박영사, 2012), 45쪽.

34) 김형배, 노동법(2012), 43쪽.

되고, 이러한 필요성의 헌법적 발현이 우리 헌법 제32조상 근로의 권리이다. 우리 헌법 제32조 제1항은 “모든 국민은 근로의 권리를 가진다. 국가는 사회적·경제적 방법으로 근로자의 고용의 증진과 적정임금의 보장에 노력하여야 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 최저임금제를 시행하여야 한다”고, 제2항은 “모든 국민은 근로의 의무를 진다. 국가는 근로의 의무

동의 강요, 임의적 해고 등이었다. 이러한 피해를 시정하고 경제적 약자인 근로자의 권익을 보호하려는 것이 근로조건법정주의이다.³⁶⁾

특히, 근로자와 사용자 간의 근로관계의 종료에 초점을 맞춰 위와 같은 인간의 존엄성 보장을 위한

로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정”된다고 하는 구체적 의미는 무엇인가? 기간제 근로자에게 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권이 인정된다는 것은 그 근로자에게 그 기대권이 부여되어 근로자는 이를 권리

고, 이러한 기대권은 갱신 거절시에는 존재하는 것으로 인정되어야 한다. 그리고 법원이나 노동위의 최종적 판단이나 사용자의 그 인정 의사표시는 그 기대권 발생의 나머지 요건사실에 해당하므로, 이를 인정하는 법원이나 노동위의 최종적 판단이 있거나 사용자가 이에 대하여 인정하는 의사표시가 있는 경우에는 근로자는 그 시기에 그 기대권을 완전

3.4. 기간만료 후의 근로관계에 대한 고찰

3.4.1. 소의 이익의 문제

근로자가 해고무효확인을 구하더라도 사실심 변론종결 당시에 정년의 도래,<

도는 지극히 정당하다. 만일 갱신된 기간 만료로 인하여 소의 이익이 없다고 한다면, 사실심 변론종결시까지 기간 도래가 이뤄지지 않게 근로계약기간을 장기로 설정하지 않은 기간제 근로자는 갱신 거절에 대하여 실질적으로 다룰 수 없는 불합리가 발생하기 때문이다.

그렇다면

행위로 금반언의 법리에 반하여 허용되지 않는다고 봐야 하고, 법원이 그 갱신 거절이 없었더라면 갱신되었을 근로계약상 정해진 기간의 만료를 직권으로 고려하여 소각하판결을 하는 것은 헌법 제32조 제3항상의 인간의 존엄성 보장을 위한 근로조건법정주의에 반하므로 허용되지 않는다고 본다.

이 있거나 갱신 거절 이후 사용자가 심히 어려운 재정난에 빠져 가까운 장래에 도산이 현실화할 위험이 현존하는 경우에는 그 기대권 행사는 권리남용으로서 예외적으로 허용되지 않는다고 봐야 한다.

이와 같은 예외적인 근로계약 갱신기대권의 제한

을 두고 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등”으로, 양 판단요소는 서로 구분되지만, 판단요소가 상당한 정도로 중첩되어 그 판단요소의 실제 적용은 수렴될 수밖에 없다. 결국 양 법리는 그 요건과 효과 면에서 거의 수렴되는 상황이다. 다만, 전자의 법리는 후자의 법리에 적용되는 기대권의 포기나 기대권 행사의 권리남용에 의한 금지가 적용된다고 보기는 어렵다.

실무적으로는 기간제 근로자는 부당해고구제소송 등에서 근로자에게 조금이라도 유리한, 기간제 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 간주하는 법리를 주위적 주장으로, 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권 법리를 예비적 주장으로 한다. 그렇다면, 어떤 경우에 기간제 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 간주하는 법리를 적용하고, 어떤 경우에 근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권 법리를 적용하는가? 대법원 2007.9.7. 선고 2005두16901 판결 등이 판시하는 바와 같이 처분문서인 계약서에 기간이 설정되어 있음에도 기간제 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 간주하는 것은 쉽지 않다. 그럼에도 근로계약상 설정된 기간이 형해화된 사정, 즉 ① 기간제 근로계약이 자동적으로 갱신되는 조항이 있는 등으로 비록 근로계약기간이 설정되어 있으나 그 기간 만료로 근로관계가 종료하지 않는다는 데에 근로자와 사용자 간 의사합치⁵²⁾가 있거나, ② 그와 같은 의사합치에 이른 것은 아니나 근로계약상 정해진 기간이 형식상 정해진 것으로 사용자나 근로자 사이에 인정⁵³⁾되는 경우에는 기간제 근로

52) 오표시무효 법리(falsa demonstratio non nocet) 참조. 이 법리는 표의자 및 그 상대방이 표시행위를 원래의 의미대로 이해하지 아니하고 이와 다른 의미로 이해한 때에는 법률행위는 표의자와 상대방이 실제로 이해한 의미대로 성립한다고 하는 법리이다(이영준, 민법총칙(박영사, 2007), 291쪽).

53) 가령, 어느 연구원이 연구직을 비롯하여 관리직, 행정직을 포함한 전체 직원에 대하여 3년으로 설정된 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결하고, 이와 별도로 ‘위촉직’이라는 이름으로 기간의 정함이 있는 근로자를 별도로 두고 있는데, 그 연구원의 사용자나 근로자들이 3년으로 설정된 기간제 근로자를 ‘정규직 근로자’로 인식하고 위촉직 근로자를 ‘비정규직 근로자’로 인식하는 경우를 상정할

자를 기간의 정함이 없는 근로자로 간주하는 법리가 적용된다고 본다. 기간제 근로자가 담당한 업무가 계속적·상시적 업무로 의원사직자(依願辭職者)를 제외한 모든 또는 대다수의 기간제 근로자에 대하여 장기간 동안 근로계약 갱신이 이뤄지거나 다회에 걸쳐 그 갱신이 이뤄진 사정이 있는 경우 등으로 사용자의 근로계약 갱신에 대한 신뢰책임이 인정되는 경우에는 기간제 근로자의 근로계약 갱신기대권 법리가 적용되는 것으로 봄이 타당하다.

이와 관련하여, “원고들은 짧게는 10년(원고 갑), 길게는 15년(원고 을) 동안 계속하여 (학원) 강사로 근무하여 왔고, 1994년 이전까지는 기간의 정함이 없이 근로를 제공하여 왔으며, 그 이후로는 근로소득세 대신 사업소득세를 공제당하고 직장의료보험에 가입하지 못하고 계약의 외양도 ‘용역계약서’라는 제목의 계약형식으로 바뀌기는 하였으나, 그러한 계약서 형식, 세금 공제 방법, 사회보장형태 등의 변경과 상관없이 실지 근무형태는 종전과 달라진 것이 없이 매년 2월에 계약을 갱신하여 왔는데 그와 같이 반복 체결된 계약이 6·7회에 이르고, 60세에 도달하였다는 사정 때문에 계약 갱신을 거절한 것으로 보일 뿐 달리 근무성적이나 업무 성과 등 근로계약의 갱신에서 고려될 다른 사정 때문에 갱신 거절을 당하였음을 기록상 알아 볼 수 없다”고 판시하여 기간제 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 간주하는 법리를 적용한 판례가 있다.⁵⁴⁾⁵⁵⁾

3.6. 입증책임 분배의 문제

근로계약 갱신에 대한 정당한 기대권이 존재하는 사정에 대한 입증책

수 있을 것이다.

54) 대법원 2006.12.7. 선고 2004다29736 판결.

55) 그러나 기간제 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 간주하는 법리를 적용하면서 판례가 고려하는 요소에는 일관성이 있다고 할 수 없다. 대법원 2007.9.7. 선고 2005두16901; 대법원 2006.2.24. 선고 2005두5673; 서울고등법원 2005.7.7. 선고 2004누14597; 서울고등법원 2005.5.3. 선고 2004누11598; 서울고등법원 2005.2.4. 선고 2003누14675; 서울행정법원 2005.5.3. 선고 2004구합18689,18702(병합) 등 참조.

임은 근로자에게 있다고 본다. 그 사정은 근로계약 갱신이 이뤄지는 권리 근거규정의 요건사실로 볼 수 있기 때문이다. 따라서 근로자는 위 판례가 실시한 그 판단요소에 관한 구체적 사정을 입증하여 그 정당한 기대권의 존재를 입증하여야 한다. 반면, 사용자는 갱신 거절의 정당성을 입증해야 한다. 해고의 정당한 이유에 대하여는 사용자가 이를 입증해야 한다는 것이 판례인데,⁵⁶⁾ 그 갱신기대권이 인정됨에도 이에 반하여 부당하게 행해진 갱신 거절이 무효라는 법리는 해고제한의 법리가 유추적용된 것이므로,⁵⁷⁾ 그 갱신 거절의 정당성은 해고의 정당성에 상응하기 때문이다.

이와 관련하여 주목할 만한 판결이 있다. 서울중앙지방법원 2009.3.27. 선고 2008가합61153, 98711 판결은 “피고의 행당지점장이 작성한 2007.10.12.자 확인서에 의하면 ‘원고가 출근시간이 늦고, 업무에 소홀하여 지장을 초래했으며, 고객응대가 불량하였고, 상품판매 실적도 극히 저조하였다’는 것을 계약갱신 거절의 이유로 들었다. …중략… ③ 2006년 창구모니터링 결과 고객만족도 점수가 양호한 점, ④ 원고의 출근 교통편 이용시간대 등에 비추어 볼 때, 행당지점장의 원고에 대한 근무평정은 합리적 근거나 공정성을 갖추었다고 보기 어렵고, 을 제10호증, 을 제11호증의 각 기재만으로 행당지점장의 원고에 대한 근무평정이 정당하다고 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 행당지점장의 원고에 대한 2006년 상반기, 하반기 및 2007. 2.의 근무평정은 합리적 기준에 따라 공정하게 심사한 결과라고 보기 어려우므로, 이에 근거하여 피고가 이 사건 근로계약의 갱신을 거절한 것은 합리적 이유가 없어 무효이다”라고 판시하여, 갱신 거절의 정당성에 대한 입증책임이 사용자에게 있다는 점을 확인하고 있다.⁵⁸⁾⁵⁹⁾

56) 대법원 1992.8.14. 선고 91다29811 등.

57) 대법판결이 위 법리 실시의 참조조문으로 근로기준법 제23조(해고 등의 제한 조항)를 적고 있다는 점에서 그와 같은 사실을 알 수 있다.

58) 그 점이 위 판례상 명백하게 드러나는 것은 아니다. 다만 위 사건에서 근로자는 위와 같은 입증책임 분배에 입각하여 자신에 대한 근무평정의 공정성에 관하여 사용자가 입증해야 한다고 주장하였고, 이에 대하여 재판부는 “을 제10호증, 을 제11호증(사용자가 제출한 증거임)의 각 기재만으로 행당지점장의 원고에 대한 근무평정이 정당하다고 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거

3.7. 현행 기간제법 하에서의 근로계약 갱신기대권의 유용성 검토

현행 기간제법 제4조 제1항은 원칙적으로 2년을 초과하지 않는 범위 내에서 기간제 근로자를 사용할 수 있도록 하여 기간제 근로자의 근로계약 갱신기대권 법리의 유용성이 상당 부분 퇴색한 것도 사실이다. 그러나 그 유용성이 퇴색했다는 의미는 기간제 근로자의 사용이 위 조항에 의하여 상당 정도로 억제되어 그 법리를 주장할 여지가 줄어들었다는 데서 기인하는 것이지 그 법리의 타당성이나 적절성이 상실된 것에서 비롯된 것은 아니다. 즉 현행 기간제법이 그 사용의 예외사유를 비교적 폭넓게 설정하고 있다는 점에서 그 법리의 유용성이 여전히 있는데, 동법 제4조 제1항 제4호 내지 제6호에 해당하는 경우로 계속적·상시적 업무를 담당하는 기간제 근로자를 장기간 또는 다회에 걸쳐 반복 갱신하여 사용하는 등으로 사용자의 그 신뢰책임을 인정하기 충분한 경우에는 그 법리의 유용성이 여전히 인정된다고 본다.⁶⁰⁾ 또한, 동조 제1항의 그 원칙이 적용되는 경우에도 2년을 초과하지 않는 범위 내에서 계속적·상시적 업무를 담당하는 기간제 근로자를 다회에 걸쳐 반복 갱신하여 사용하는 등으로 사용자의 그 신뢰책임을 인정하기 충분한 경우에도 그 법리의 유용성이 인정된다고 본다.

이와 관련하여, 그 갱신기대권이 현행 기간제법 하의 기간제 근로자 사용기간인 2년의 범위 내에서만 인정되는지가 쟁점이 된 사안에서 서울고등법원 2011.8.18. 선고 2011누9821 판결⁶¹⁾은 “위 규정들의 입법취지

가 없다”고 판시하여 근로자의 주장을 받아들였는바, 이러한 점을 고려하면 그 입증책임을 사용자에게 있다고 판시한 것으로 볼 수 있는 것이다.

59) 이 판결은 항소심은 서울고등법원 2009.11.13. 선고 2009나38423에서도 유지되었고, 이에 대하여 피고가 상고하였으나 대법원은 심리불속행판결로 이를 기각하였다(대법원 2010.4.15. 선고 2009다103370).

60) 다만 제1호 내지 제3호의 사유의 경우에는 그 법리는 적용될 여지가 없는데, 그것은 기간 설정의 객관적이고 정당한 사유가 있는 경우까지 그 법리를 적용한다면 그 기간제 근로자는 사실상 기간의 정함이 없는 근로자와 같은 효과를 부여받게 되고 이렇게 되면 그 사유를 설정한 의미가 상실되기 때문이다.

61) 이 판결에 불복하여 원고들은 대법원에 상고하였으나 대법원은 심리불속행판결로 이를 기각하였다(대법원 2011.11.24. 선고 2011두2306).

는 기간제 근로계약의 남용을 방지함으로써 기간제 근로자 지위의 안정화라는 목표와 사용자가 경기변동에 따라 고용량을 조절할 수 있는 노동시장의 유연성 제고라는 목표를 조화롭게 추구하기 위함이고, 이러한 입법취지 등에 비추어 볼 때 법 제4조 제2항은 강행규정으로 봄이 타당하다. 위 규정들의 내용과 체계 및 입법취지, 기간제법이 기간제 근로자의 총 사용기간을 원칙적으로 2년으로 제한할 뿐 다른 나라의 입법례처럼 기간제 근로계약의 체결결에 정당한 객관적 사유의 존재를 요구하거나 기간제 근로계약의 반복적 체결이 가능한 횟수를 제한하고 있지 않는 점 등에 비추어 볼 때, 기간제법 시행 이후에는 사용자는 원칙적으로 기간제 근로계약을 2년의 기간 내에서 계약기간을 자유롭게 정할 수 있음은 물론 동일한 내용으로 반복하여 체결할 수도 있지만 총 사용기간이 2년을 초과하는 때에는 해당 기간제 근로자에게 근로계약기간의 정함이 없는 근로자로서의 지위가 인정되므로, 기간제법 시행 이후에 신규로 체결되는 기간제 근로계약은 근로관계가 2년의 기간 내에 종료될 것이 예정되어 있어 근로자에게 총 사용기간이 2년을 초과하는 재계약이 체결될 수 있으리라는 기대권이 인정될 수 없다고 봄이 타당하다”라고 판시한 바 있다.

그러나 2년의 범위 내에서도 얼마든지 사용자의 신뢰책임이 발생할 여지가 있기 때문에 그 신뢰책임이 발생하는 경우에는 기간제 근로자의 근로계약 갱신기대권 법리를 적용하여 기간제 근로자의 근로관계 존속을 보호할 필요가 있다는 점에서 위와 같은 판결은 수긍하기 어렵다. 또한 그 기간제 근로자를 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 보는 것은 동법 제4조 제2항에 의한 것이고, 이것은 기간제 근로자의 근로관계 존속 보호를 위하여 입법화된 것이므로 이를 근거로 그 갱신기대권을 2년의 범위 내로 제한하여 그 기간제 근로자의 근로관계 존속 보호를 부인하는 것은 그 입법취지를 몰각시키는 법해석이어서 찬성하기 어렵다.⁶²⁾

62) 위 판결에 대한 자세한 비판은 최창귀, “기간제근로자의 갱신기대권의 제한”, 대한변협신문 제418호(대한변호사협회, 2012), 12쪽 이하를 참조 바람.

3.8. 근로계약 갱신기대권 법리의 한계와 입법적 해결의 필요성

그럼에도 이 법리의 한계도 있다. 즉 근로계약 갱신기대권 법리의 근거를 신뢰책임에서 찾는 경우 사용자가 그 책임의 빌미를 주지 않을 정도로 기간제 근로자에 대한 노무관리를 철저하게 하면 기간제 근로자는 그 갱신기대권을 획득하기 어려운 상황에 직면할 수밖에 없다.⁶³⁾ 이 경우 기간제 근로자의 근로관계 존속을 보호하기 어렵게 된다.

그러므로 기간제 근로자의 근로관계 존속 보호를 위한 근본적 해결책은 기간제 근로자를 사용할 수 있는 객관적이고 정당한 사유를 한정하는 입법을 하는 것이라고 본다. 이와 관련하여 통합진보당이 발의한 기간제법 개정안은 주목할 만하고 그 개정안이 통과되는 경우 기간제 근로자의 고용 안정 확보에 크게 이바지할 것으로 본다.⁶⁴⁾

63) 이와 같은 점은 일본에서도 마찬가지라고 한다(스게노카즈오 저/이정 역, 앞의 책, 184-185쪽).

64) 통합진보당이 발의한 기간제법 개정안의 핵심적 내용은 기간제법 제4조의 개정이고, 이는 다음과 같다.

제4조(기간제 근로자의 사용)

① 사용자는 다음 각 호의 경우에만 기간제 근로자를 사용할 수 있다.

1. 근로자의 출산·육아 또는 질병·부상 등으로 인하여 발생한 결원을 대체할 경우
2. 계절적 사업의 경우
3. 일정한 사업의 완료에 필요한 기간을 정한 경우

② 사용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기간제 근로자를 최초 사용 시부터 기간의 정함이 없이 고용한 것으로 본다. 다만, 기간제 근로자의 명시적 의사에 반할 수 없다.

1. 제1항 각 호에 해당하지 않음에도 기간제 근로자를 사용하는 경우
2. 제1항 각 호에 해당하더라도 각 호의 사유가 해소된 후에도 기간제 근로자를 사용하는 경우
3. 제1항 각 호의 사유가 해소되지 않은 경우에도 1년을 초과하여(기간제 근로계약의 반복갱신 등의 경우에는 그 계속근로한 총기간이 1년을 초과하여) 기간제 근로자를 사용하는 경우

민주통합당도 기간제법 개정안을 당론으로 발의하였는데, 이와 관련된 개정안은 다음과 같다. 이 개정안은 기간제 근로자의 사용사유를 객관적이고 정당한 사유로 한정하는 통합진보당의 개정안과는 달리 그 사유를 보다 폭넓게 설정된 것이 특징이다(아래 제4호 내지 제6호).

III. 결론에 부쳐

우리 헌법 제34조상의 인간다운 생활을 하고 헌법 제10조에서 과생하는 인격의 자유로운 발현을 이루는 삶을 영위하기 위해서는 그 물질 토대가 있어야만 한다. 근로자의 경우 근로관계 형성 및 유지가 그 물질 토대의 핵심이 될 수밖에 없고, 이를 위해서는 근로관계 존속 보장이 중요한 기능을 수행하기 마련이다. 기간제 근로자의 근로계약 갱신기대권 법리는 위와 같은 한계에도 불구하고, 앞서 본 바와 같은 입법이 이뤄지지 않는 상황에서는 기간제 근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 간주하는 법리와 더불어 기간제 근로자의 근로관계 존속 보장에 크게 이바지한다고 본다. 이는 기간제 근로자의 인간다운 삶과 인격의 자유로운 발현에 이바지할 것이다.

한 가지 진하게 남는 아쉬움과 안타까움이 있다. 대법원 1996.8.29. 선고 95다5783 판결(전원합의체)이 없었더라면, 1년을 초과하는 근로계약기간을 정한 경우에 그 근로계약은 1년의 계약기간을 가진 근로계약으로 인정되고 그 이후의 근로관계는 특별한 사정이 없는 한 기간의 정함이

제4조(기간제 근로자의 사용)

① 사용자는 다음 각 호의 경우에 한하여 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서(기간제 근로계약의 반복갱신 등의 경우에는 그 계속 근로한 총기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서) 기간제 근로자를 사용할 수 있다.

1. 출산·육아, 질병·부상, 휴직 등으로 인한 결원 대체의 경우
2. 계절적 사업의 경우
3. 일정한 사업완료에 필요한 기간을 정한 경우
4. 근로자가 학업, 직업훈련 등의 사정으로 자신의 의사에 따라 기간을 정한 경우
5. 정부 또는 지방자치단체의 복지정책·실업대책 등에 따라 일자리를 제공하는 경우로서 대통령령이 정하는 경우
6. 그 밖에 제1호 내지 제5호에 준하는 합리적인 사유가 있는 경우로서 대통령령이 정하는 경우

② 사용자가 제1항 각호의 사유가 없거나 소멸되었음에도 불구하고 기간제 근로자로 사용하거나 2년을 초과하여 기간제 근로자로 사용하는 경우에는 그 기간제 근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 본다.

없는 것으로 보아야 한다는 대법원 1989.7.11. 선고 88다카21296 판결이 유지되었더라면, 기간제 근로계약이 남용되어 기간제 근로자의 사용이 큰 흐름이 될 정도로 만연하였을까 하는 점이다. 이 지점에서 대법원 판례가 가지는 중요성과 역할을 상기할 수밖에 없다. 더불어 법률가의 역할의 중요함을 다시 한 번 깨닫고 그 무거운 책임감을 새삼 느낀다.

<참고문헌>

- 계희열, 헌법학 중, 서울: 박영사, 2007.
- 이영준, 민법총칙, 서울: 박영사, 2007.
- 김형배, 노동법, 서울: 박영사, 2007.
- 김형배, 노동법, 서울: 박영사, 2012.
- 菅野和夫 저/이정 역, 일본노동법, 서울: 박영사, 2007.
- 강성태, “기간의 정함이 있는 근로계약의 규율”, 한국노동법학회, 노동법학 제7호, 관악사, 1997, 161-192쪽.
- 김기수, “기대권”, 국가고시학회, 고시계 제28권 제9호, 고시계사, 1983, 69-78쪽.
- 김인재, “기간제 근로자의 재임용 기대권”, 월간 노동법률 제174호, 중앙경제사, 2005, 35-40쪽.
- 김 진, “기간을 정한 근로계약의 부당해고 구제”, 중앙노동위원회, 조정과 심판 제 23호, 문원기획사, 2005, 39-51쪽.
- 노상현, “기간의 정함이 있는 근로계약과 해고법리”, 한국노동법학회, 노동법학 제 16호, 관악사, 2003, 1-28쪽.
- 노호창, “헌법상 근로권의 내용과 성격에 대한 재해석”, 서울대노동법연구회, 노동법연구 제30호, 관악사, 2011, 125-164쪽.
- 도재형, “기간제 근로계약 갱신 거절권의 제한”, 서울대노동법연구회, 노동법연구 제24호, 관악사, 2008, 147-186쪽.
- 박수근, “근로계약의 有期化 現状에 따른 부당해고 구제절차에 있어 구제이익”, 중앙노동위원회, 조정과 심판 제10호, 문원기획사, 2002, 3-27쪽.
- 신권철, “기간제 근로계약의 무기계약으로의 전환”, 서울대노동법연구회, 노동법연구 제30호, 관악사, 2011, 197-251쪽.
- 유성재, “기간의 정함이 있는 근로계약에 대한 입법론적 고찰”, 한국노동법학회, 노동법학 제12호, 관악사, 2001, 119-140쪽.
- 이은영, “임시직 근로자의 계속근로와 퇴직금”, 민사판례연구회, 민사판례연구 제18호, 박영사, 1996, 257-287쪽.
- 조임영, “기간제 고용에 관한 현행법제의 문제점과 입법적 과제”, 중앙법학회, 중앙법학 제6집 제3호, 이화문화사, 2004, 405-432쪽.
- 최창귀, “기간제근로자의 갱신기대권의 제한”, 대한변호사협회, 대한변협신문 제418호, 2012, 12쪽.
- 고용노동부, “2010 고용형태별근로실태조사 보고서”, <<http://laborstat.moel.go.kr/include/download.jsp?filepath=/labor/fileload/pdata/&filename=2010년고용형태별근로실태조사보고서.pdf>>, 검색일: 2012.7.13.
- 통계청, “중사상지위별 취업자”, <http://kosis.kr/gen_etl/start.jsp?orgId=101&tblId=DT_1DA7010&conn_path=12&path=고용?노동?임금> 고용 > 경제활동인구조사 > 취업자(63년~현재)중사상지위별 취업자>, 검색일: 2012.7.6.

<Abstract>

A Study on the Legal Principle of the Right of Fixed-term Employees to Expectation for Labor Contract Renewal

Oh, Yun-Shik

Attorney at Law, Lawjung

Last year, Korean Supreme Court declared a legal principle of “Reasonable Right of Fixed-term Employees to Expectation for Labor contract Renewal”, a principle that protects the fixed-term employees and their continuation of employment relationship, and I agree with the Court.

In order to explain the theoretical background of the principle, this thesis will explore the following:

Firstly, the right of fixed-term employees to expect labor contract renewal is based on confidence liability ruled by the general principle that working conditions should be stipulated by law, a principle which protects the human dignity. Secondly, the right to the expectation for labor contract renewal is acquired as a complete one only if the condition is met, which is either a confirmed judicial decision or judgment, or a manifestation of intention from the employer, recognizing the right. Thirdly, even if the renewed term of the employee is over, the employer can not claim the expiration of the term due to estoppel. Also, the Court or the Labor Relations Commissions can not dismiss the case only because there is no interest in such legal action due to the expiration of the renewed term, and such claim of the employer must be excluded till retiring age of regular employees, unless there are exceptional reasons to limit such expectation right. Lastly,

the employee must prove specific circumstances showing the existence of the right to the expectation for labor contract renewal, in order to make such right be recognized by either a judicial decision or judgement, whereas the employer must prove the legitimacy of his denial of labor contract renewal.

Key Phrases : Fixed-term employees, Right to expectation for contract renewal, Confidence liability, General principle that working conditions should be stipulated by law, Protection of continuation of employment relationship.